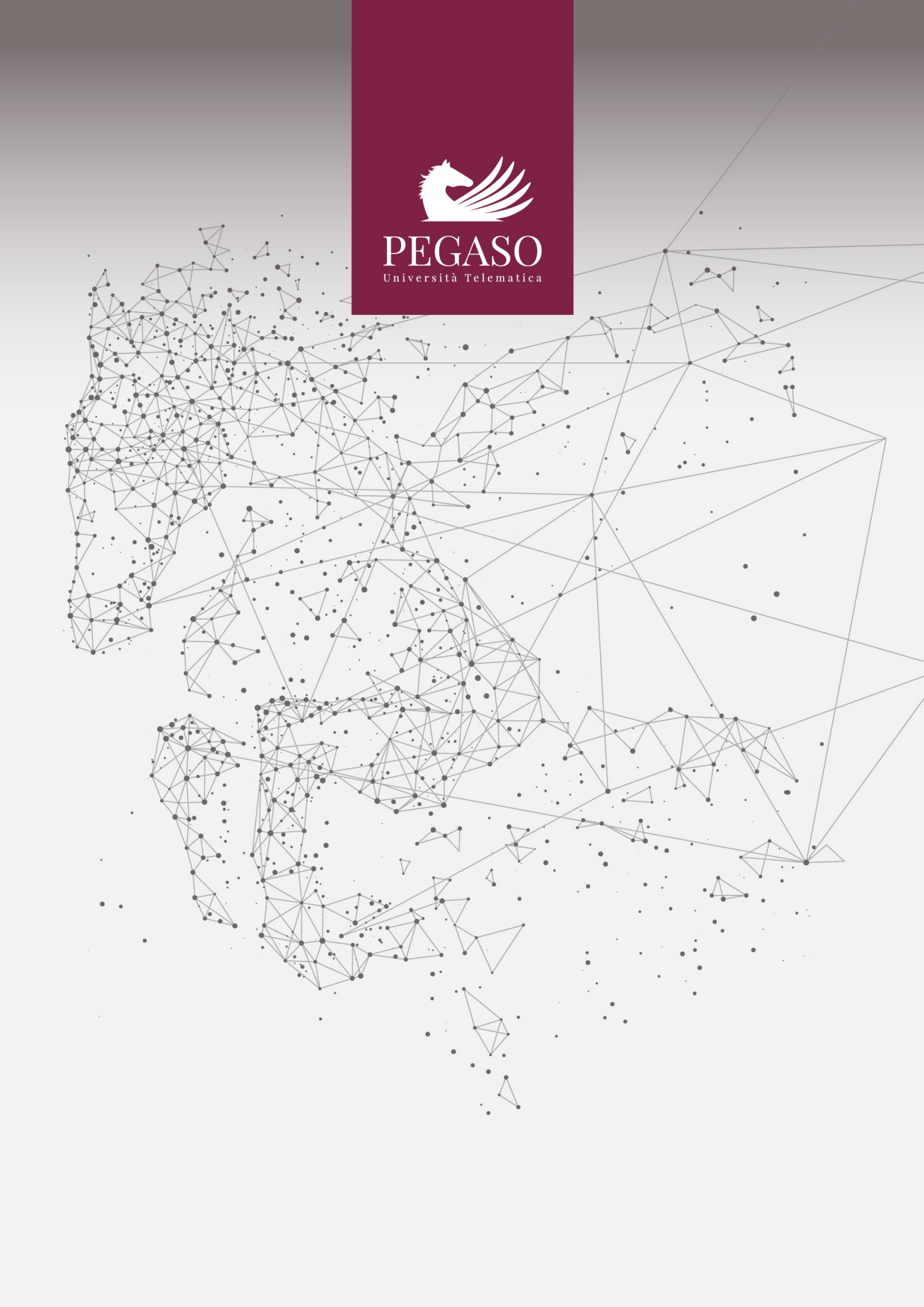

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1 L'INFORMATIVA 3

2 LA BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 6

3 L'ATTIVITÀ DI PROFILAZIONE 9

BIBLIOGRAFIA 12

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1 L'informativa

In linea generale, la raccolta e il trattamento di dati personali di altri individui per uso strettamente personale è libera ed è consentita (ad esempio per i dati, tipo nome, cognome, email, ecc., nelle proprie agende cartacee o elettroniche).

Diversamente, quando i dati siano raccolti ed utilizzati per altre finalità (ad esempio per una piattaforma di *e-commerce* che tratta i dati degli utenti), il trattamento, per essere lecito, deve rispettare alcune regole fondamentali, tra cui quelle relative alle informazioni da fornire all'interessato ed alla base giuridica che consente tale trattamento.

Chi intende effettuare un trattamento di dati personali deve prima fornire all'interessato alcune informazioni mediante la c.d. "informativa" (ex art. 13 e 14 Reg. UE 2016/679) al di fine di renderlo edotto circa le modalità in cui avviene lo specifico trattamento e di metterlo nella condizione di esercitare i propri diritti.

L'informativa, però, è condizione non tanto del rispetto del diritto individuale del (potenziale) interessato di essere informato, ma risponde soprattutto all'obbligo del titolare del trattamento di assicurare la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla fase di progettazione dei trattamenti stessi, e di essere in grado di comprovarlo in qualunque momento (in base al principio di *accountability*).

In particolare, l'informativa deve indicare:

- l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se del caso, di un suo rappresentante;
- i dati di contatto del RDP o DPO, se previsto;
- le categorie di dati trattati e la finalità del trattamento (se i dati vengono trattati divisi per categorie, a quale fine, per quanto tempo, mentre se i dati verranno trasferiti all'estero, attraverso quali strumenti);

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- la base giuridica del trattamento (quindi se si tratta di trattamento basato su un contratto oppure su consenso o giustificato da leggi, legittimi interessi e via dicendo);
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di tale rifiuto;
- se il titolare ha intenzione di utilizzare i dati per una finalità diversa da quella per la quale sono stati raccolti;
- i soggetti destinatari (anche per categorie) ai quali i dati possono essere comunicati (ad esempio, un'azienda può trasmettere dati al proprio commercialista o consulente del lavoro) e l'ambito di diffusione dei dati medesimi (l'indicazione di soggetti terzi non può cioè essere generica);
- se il titolare ha intenzione di trasferire i dati in paesi extra UE, nel qual caso deve chiarire se esiste o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE;
- il periodo di conservazione dei dati oppure l'indicazione dei criteri per determinarlo;
- i diritti dell'interessato (quali il diritto di accesso ai dati personali, il diritto di rettifica e di cancellazione degli stessi o di limitazione del trattamento che lo riguardano, il diritto di opporsi al trattamento, il diritto di revocare il consenso, il diritto di presentare reclamo all'Autorità di controllo, nonché l'eventuale diritto alla portabilità);
- se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, deve essere specificato indicando anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l'interessato.

Qualora l'informativa venga fornita su un sito web, essa deve indicare anche i cookie che veicola il sito stesso, le modalità di disabilitazione dei cookie (ad esempio, tramite le opzioni del browser), e nel caso di cookie di terze parti, il link alle pagine delle privacy policy dei loro servizi.

Nel caso di dati raccolti presso terze parti, ai sensi dell'art. 14 GDPR l'informativa deve presentare anche l'indicazione della fonte da cui hanno origine i dati medesimi e se del caso l'eventualità che i dati provengano da una fonte accessibile al pubblico.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'omessa o inidonea informativa è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che può raggiungere i 20.000.000 di Euro (ex art. 83, par. 5, GDPR).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2 La base giuridica del trattamento

Quando si deve procedere al trattamento di dati personali è necessario identificare quale ciò che lo legittima – la c.d. base giuridica del trattamento - all'interno di quelle di seguito indicate e previste dall'art. 6 del GDPR:

- consenso dell'interessato, per cui il trattamento dei dati viene esplicitamente autorizzato dall'interessato per una o più specifiche finalità (ad esempio, per l'uso dei dati dell'interessato per finalità di marketing);
- esecuzione di un contratto o di previsioni precontrattuali, per cui il trattamento è necessario per adempiere appunto ad un contratto concluso dall'interessato;
- adempimento di un obbligo di legge, per cui il trattamento dei dati è imposto da una legge, regolamento, e via dicendo (si pensi al trattamento del dato sanitario nell'ambito della medicina preventiva oppure del lavoro);
- interesse vitale dell'interessato, per cui il trattamento è necessario per salvaguardare la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica e non vi è possibilità che il trattamento sia fondato su altra base (ad esempio, se si deve procedere con un intervento di emergenza o salvavita che richiede di conoscere i dati sulla salute dell'interessato);
- esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico, per cui il trattamento è necessario per svolgere un compito connesso ai pubblici poteri (così, durante le consultazioni elettorali gli scrutatori o i rappresentanti di lista possono venire a conoscenza di dati personali anche di natura sensibile);
- interesse legittimo del titolare, per cui il trattamento è necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti i dati, a condizione che non prevalgano su esse gli interessi o diritti dell'interessato (in proposito, il Considerando n. 48 formula l'esempio del trattamento dei dati all'interno di un gruppo imprenditoriale a fini amministrativi).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Quella da ultimo indicata è probabilmente la base giuridica più "insidiosa", in quanto il trattamento può essere effettuato solo a seguito di un bilanciamento tra interessi e diritti del titolare che chi lo effettua deve compiere.

E si deve anche ricordare che la base giuridica si trova pure tra gli elementi essenziali dell'informativa e deve essere chiaramente evidenziata in riscontro ad una istanza di accesso.

Andando ad approfondire il discorso sul consenso al trattamento dei dati, si nota che questo è solo una delle basi giuridiche previste dal GDPR e che è dovere del titolare del trattamento valutare quale tra esse è la base giuridica più idonea per il trattamento che intende porre in essere.

Quella rappresentata dal consenso dovrebbe essere allora una base giuridica quasi residuale: se non vi un contratto, né un obbligo per il titolare del trattamento imposto da norme, è chiaro che il consenso rappresenta l'ultima base giuridica esercitabile dal titolare, affinché esso possa essere autorizzato a raccogliere e trattare i dati dell'interessato.

Dunque, il consenso era centrale nella vecchia normativa, quando vi era una visione proprietaria del dato.

Oggi invece non è più così, considerando che un individuo è costantemente soggetto a numerosi trattamenti e che la tutela della circolazione del dato è essenziale.

Quanto alle sue forme, in base all'art. 4 del GDPR il consenso è qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso esprime il proprio assenso, mediante una dichiarazione o un'azione positiva inequivocabile, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Il Regolamento prevede poi alcuni casi in cui il consenso deve essere esplicito, ad esempio per il trattamento di particolari categorie di dati ai sensi dell'art. 9 GDPR, per il trattamento di dati sensibili, per i processi decisionali automatizzati come la profilazione oppure per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi (art. 49).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le pubbliche amministrazioni, al contrario dei privati e degli enti pubblici economici, non devono richiedere il consenso dell'interessato, purché il trattamento sia effettuato nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3 L'attività di profilazione

Della profilazione il nuovo regolamento *privacy*[1] (GDPR) dà una definizione chiara all'articolo 4.

Essa è «*qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica*».

Lo stesso GDPR (sigla che si userà di seguito per indicare il Regolamento di cui si tratta), fornisce altre indicazioni al Considerando 24[2].

Esso stabilisce che al fine di determinare se una data attività sia da considerarsi come attività di profilazione «*è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet, compreso l'eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali*».

Gli elementi caratteristici della profilazione sono costituiti quindi dal trattamento di dati personali, effettuato in maniera automatizzata, con il fine di valutare determinati aspetti (interessi, affidabilità economica ecc.) di una determinata persona.

L'attività di profilazione può essere effettuata per gli scopi più disparati, come ad esempio:

- la messa a disposizione di servizi o prodotti mirati e conformati sugli interessi mostrati dall'utente;

[1] Regolamento 2016/679.
[2] I "Considerando" del regolamento europeo sono assimilabili alle premesse nei contratti: esse non hanno mero valore di introduzione, ma fanno parte integrante del testo legislativo e hanno un grande valore per la comprensione, interpretazione e applicazione del regolamento stesso.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- la fornitura di pubblicità personalizzata in base ai comportamenti online degli utenti;
- l'analisi e il monitoraggio dei comportamenti *online* degli utenti per determinarne ad esempio l'affidabilità creditizia o il rendimento professionale;
- lo sfruttamento economico dei profili degli utenti.

Il Garante della protezione dei dati personali ha avuto modo di pubblicare alcune delle fondamentali linee guida in relazione all'attività di profilazione[3].

Le stesse formulano forniscono specifiche indicazioni circa:

- le modalità e contenuto dell'informativa resa agli interessati, anche in relazione all'esplicitazione delle diverse finalità e alle modalità del trattamento dei loro dati personali;
- la richiesta del consenso degli interessati per finalità di profilazione, nonché rispetto del diritto di opposizione degli interessati;
- il rispetto del principio di finalità nella conservazione dei dati personali degli utenti[4].

Un presupposto fondamentale da cui partire e su cui bisogna porre l'attenzione è dato dall'informativa che deve essere resa agli utenti, ai fini dalla loro preventiva consapevolezza circa i possibili impieghi delle informazioni loro riferibili.

Essa costituisce uno passaggio fondamentale per consentire agli interessati medesimi di esprimere o meno il proprio consenso ai trattamenti di dati che li riguardano: a seguito di una necessaria, personale e – lo si ripete – consapevole valutazione sull'impatto che tali trattamenti potranno in effetti avere sul loro diritto alla protezione dei dati personali.

Costituisce un preciso obbligo ed una condizione appunto necessaria di conformità alla disciplina il fatto di garantire che l'informativa sia per gli utenti facilmente accessibile, ad esempio

[3] Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione *on line* del 19 marzo 2015.

[4] Secondo la norma «*i dati personali oggetto di trattamento sono: (...)*
e) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati (...)» (art. 11, 1 comma, lett. e, Codice Privacy).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

con un solo *click* dalla pagina del dominio cui l'utente accede, nonché che essa sia formulata in modo chiaro, completo ed esaustivo.

Del pari è necessario che, a fronte di eventuali aggiornamenti o modifiche di tale documento, gli interessati siano posti nella condizione di comprendere e valutare i cambiamenti apportati, anche mediante raffronto tra le diverse versioni dell'informativa eventualmente susseguitesi nel tempo.

Viene considerata inoltre una *best practice* quella di redigere l'informativa su più livelli o strati, ciascuno dei quali fornisca le informazioni fondamentali sul trattamento dei dati, via via con un maggior livello di completezza al variare del livello o strato, in particolare circa le finalità e le modalità della profilazione che viene effettuata dal titolare del trattamento.

In relazione al consenso degli interessati bisogna precisare che il consenso alla profilazione è un consenso specifico ed ulteriore, il quale si sottrae alla esenzione dal generale obbligo del consenso per tutte le attività di trattamento che siano svolte al fine specifico di eseguire contratti conclusi tra il fornitore del servizio e gli utenti (sicché occorrerà comunque, in connessione ad esse, ricevere il consenso di cui si tratta).

Si faccia l'esempio di un operatore di posta elettronica che, oltre al servizio inerente alle *email*, effettui attività di profilazione per inviare pubblicità mirata.

In tale caso il Garante avverte che per il conseguimento di eventuali finalità di profilazione, ulteriori rispetto a quelle direttamente e strettamente inerenti la messa a disposizione della specifica funzionalità del servizio di posta elettronica – in particolare per la visualizzazione, da parte dell'utente autenticato, di messaggi di testo tesi alla fornitura di pubblicità comportamentale personalizzata –, è invece necessario che i titolari provvedano ad acquisire il preventivo ed informato consenso dei propri utenti.

Infine, il trattamento dei dati per finalità di profilazione non deve essere più notificato al Garante Privacy (come stabiliva l'articolo 37, comma 1, lettera d, Codice Privacy), ma il titolare del trattamento dovrà effettuare la DPIA.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- R. ACCIAI, *Il diritto alla protezione dei dati personali. La disciplina sulla privacy alla luce del nuovo Codice,* Maggioli, Rimini, 2004.
- P. MARINI, *GDPR – Il nuovo regolamento europeo sulla privacy*, Milano, Ipsoa, Milano, 2018.
- G.M. RICCIO, G. SCORZA ed E. BELLISARIO (a cura di), *GDPR e normativa privacy*, Ipsoa, Milano, 2018.
- M. SOFFIENTINI, *Privacy 2018*, Ipsoa, Milano, 2018.
- B. TASSONE e B. GIUBILEI, *Tutela dei diritti e della privacy online e offline dei soggetti deboli*, in M. IASELLI (a cura di), *Trattato delle investigazioni digitali*, Giuffré, Milano, 2020, 134 ss.
- R. PARDOLESI (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali,* Vol. I, Giuffrè, Milano, 2004.
- R. ZACCARIA, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, VI edizione, Cedam, Padova, 2007.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).